TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Despacho 01
Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA

Santa Marta D.T.C.H., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA	
Radicación número:	**47-001-3333-005-2010-00684-01**
Actor:	Gerardo Antenor Lemus Orozco
Demandado:	Nación – Ministerio de Ambiente, distrito de Santa Marta – Curaduría Urbana No.2 – DIMAR - Pevesca Ltda. e Inversiones Vives Ltda. en Liquidación
Medio de control:	Acción Popular (L472/1998)
Tema:	Protección de los derechos e intereses colectivos

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, Pevesca Ltda. e Inversiones Vives Ltda. en Liquidación, en contra de la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante la cual se declaró la carencia actual del objeto por hecho superado ante la amenaza a los derechos colectivos.

1. ANTECEDENTES

1.1. Resumen de la demanda

1. El señor Gerardo Antenor Lemus Orozco[1], presentó Acción Popular en contra de la Nación – Ministerio del Medio Ambiente, el Distrito de Santa Marta, la Curaduría Urbana No. 2, DIMAR y, Pevesca Ltda e Inversiones Vives Ltda. en Liquidación en la que **solicitó**[2] en síntesis lo siguiente:

2. Se pretende que se ordene al gerente de Pevesca Ltda. La suspensión inmediata de las acciones tendientes a efectuar la construcción de muro de cerramiento en la zona de playa por ser ésta de uso público.

3. Se ordene a la entidad competente la demolición actual de la construcción del muro de cerramiento que inició el pasado 12 de junio de 2010, sobre el área de la playa, denominada "Los Cocos", seguido a la margen derecha e izquierda de las antiguas instalaciones del restaurante "La Terraza Marina" en frente del espolón construido por el Distrito de Santa Marta.

[1] En adelante actor popular.
[2] Ver págs. 8-9 del PDF 01 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

4. Que se ordene a la sociedad Pevesca Ltda. retirar todos los elementos de construcción cono los que ha invadido el área de la playa "Los Cocos" y deje la playa en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su invasión, permitiendo el goce y utilización del espacio público en aras de la defensa de los intereses de uso público.

5. Se ordene a la sociedad Pevesca Ltda. no insistir en la acción de construcción, habida cuenta que la Curaduría no puede otorgar permisos para construcción sobre bienes de uso público.

6. Que se ordene a cada entidad demandada cumplir con lo de su competencia a fin de garantizar un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, la protección del medio ambiente y la protección real y efectiva del espacio público, su uso y goce.

7. Que se cite al proceso a las demás personas naturales o jurídicas de quienes dependa la supresión de ese daño contingente y ordéneseles adoptar las medidas que a ellas corresponda.

8. Que la sociedad Pevesca Ltda. reconozca a su favor el incentivo contenido en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

9. Que se condene en costas a las demandadas, agencias en derecho y demás honorarios contemplados en la ley 472 a favor del actor de la Acción Popular.

10. Como **fundamentos fácticos**[3] de las pretensiones, la parte actora expuso lo que se indica a continuación:

11. Manifestó que los pescadores de la zona de la playa de "Los Cocos" son usuarios naturales del área de esa playa, pues es allí donde estacionan sus canoas con posterioridad a la labor diaria.

12. Sostuvo que los peatones, turistas, y en general habitantes de la región de Santa Marta hacen uso permanente de la playa con el fin de realizar actividades turísticas y de disfrute de ese bien de uso común y público.

13. Declaró que el uso que se hace de la zona de esa playa beneficia a toda la comunidad vecina de Santa Marta.

14. Señaló que el día 12 de junio de 2010, personas identificadas como trabajadores al servicio de la sociedad Pevesca Ltda. y supuestos propietarios del área de playa iniciaron trabajos de demarcación e instalación de material de construcción para realizar obras de cerramiento de un predio ubicado en el área de la playa "Los Cocos" sector Bellavista del distrito de Santa Marta.

[3] Ver págs. 3-5 del PDF 01 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

15. Afirmó que mediante solicitud elevada el 10 de julio de 2008 ante la Curaduría Urbana segunda de Santa Marta, la sociedad Pevesca Ltda. Solicitó aprobación de planos y la expedición de la licencia de construcción en modalidad de cerramiento.

16. Declaró que mediante la Resolución No. 153 del 22 de agosto de 2008 se otorgó la licencia de construcción No. 039 en su modalidad de cerramiento a Pevesca Ltda.

17. Manifestó que el cerramiento que pretende realizar dicha firma se encuentra ubicado en zona de playa y con su realización se privaría a todos los usuarios de la región del uso, goce y disfrute de este bien de uso público de carácter colectivo.

18. Sostuvo que la Resolución acusada y mediante la cual se concede la licencia de construcción desconoce la Constitución Política en sus artículos 2,8, 58, 63, 82 en cuanto a los bienes de uso público, y la defensa de los mismos, ello por cuanto el argumento de la propiedad o posesión privadas no prevalecen ante el ejercicio de los derechos colectivos como son el uso, goce y disfrute de estos bienes para toda la colectividad.

19. Señaló que con la construcción del muro se impide el acceso y la ocupación de un área que se encuentra dentro del área de playa que, si bien puede pertenecer a un particular, éste debe sujetarse a las limitaciones que el establece la propiedad como función ecológica y social, en consecuencia, debe permitir el acceso, circulación, locomoción, ocupación transitoria, de los pescadores, turistas y transeúntes.

20. Declaró que con la construcción se vulneran los derechos colectivos al espacio público, al trabajo, a la locomoción, a la protección de las zonas de playa de los pescadores y transeúntes actuales y futuros de la playa de "Los Cocos".

21. Afirmó que el área de playa a construir se encuentra a una distancia de 24 metros lineales medidos desde la línea de la más alta marea y más alta creciente hacía dentro. Esto es, el área a cerrar se encuentra dentro de los 50 metros, medidos desde la línea de la más alta marea y más alta creciente hacía dentro, que determina el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 2324 del 10 de septiembre de 1984, como área de playa de jurisdicción de la Dimar.

22. Como **fundamentos de derecho**[4] esgrimió la parte actora lo siguiente:

- Artículo 4 de la Ley 472 de 1998
- Artículos 63 y 82 de la Constitución Política
- Artículo 674 del Código Civil
- Artículo 5 de la Ley 9 de 1989

[4] Ver págs. 6-8 del PDF 01 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

- Artículo 37 de la Ley 388 de 1997

23. En cuanto al concepto de violación, explicó que las playas y terrenos de bajamar son bienes de uso público por cuanto su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como ocurre en este caso, luego entonces, cuando Pevesca Ltda. argumenta derechos de propiedad privada para construir, se están limitando y vulnerando todos los derechos de la comunidad para el uso, goce, y disfrute de estos recursos, amenazando gravemente el sustento de los pescadores de la región quienes ubican las canoas en la zona de la playa "Los Cocos".

1.2. Posición de las partes demandadas

1.2.1. Curaduría Urbana 2[5]

24. La Curadora Urbana No. 2 presentó contestación a la demanda manifestando que desconocía si la sociedad Pevesca Ltda. está realizando la construcción de cerramiento en un lote de uso público o de un lote de propiedad de alguna entidad estatal.

25. Declaró que dentro del trámite de solicitud de licencia de construcción radicado en esa Curaduría bajo el número 47-001-2-008-0113, el cual culmino con la licencia de construcción No. 039, otorgada mediante Resolución No. 153 del 22 de agosto de 2008, la sociedad Pevesca Ltda., solicitó licencia de construcción en un inmueble en donde demuestra la propiedad a nombre de la sociedad Inversiones Vives Limitada en Liquidación, por lo tanto, la licencia de construcción fue otorgada en un inmueble cuya titularidad está registrada en la oficina de registros e instrumentos públicos de Santa Marta bajo el número 080-29554.

26. Afirmó que la licencia de construcción junto con los planos aprobados, siguieron los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación Distrital en la Demarcación No. 022 del 15 de agosto de 2008, deberá ser objeto de prueba si lo manifestado por el accionante es cierto o no y que, ese despacho no ha otorgado licencia para intervención en el espacio público.

27. Señaló que no haría ningún tipo de observación con respecto al derecho que se desea amparar con la acción popular impetrada, puesto que debe establecerse el área en donde se está realizando la supuesta construcción.

28. Informó que las licencias de construcción tienen una vigencia de 24 meses prorrogables por 12 meses; la licencia otorgada a la sociedad Pevesca Ltda. fue otorgada el 22 de agosto de 2008, lo que quiere decir culminaba el 22 de agosto de 20120 y, no se le otorgó prorroga.

[5] Ver págs. 106-107 del PDF 01 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

1.2.2. Distrito de Santa Marta[6]

29. El Distrito de Santa Marta, actuando por intermedio de apoderado judicial presentó escrito de contestación, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, manifestando que en atención a la suspensión provisional decretada, la Secretaría de Gobierno Distrital avocó el conocimiento del asunto el día 23 de junio de 2010 y por medio de acto administrativo revocó la decisión del Inspector de Policía Central de fecha 15 de junio de 2010 que amparó la posesión de encerramiento del lote identificado con No. 11 frente al área de la playa "Los Cocos", decretando medida provisional de *statu quo* sobre la construcción del encerramiento.

30. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que desde el año 1997 mediante la expedición de la Ley 388 de ese año se trasladó la función de demarcar el área urbana, rural y en especial el litoral costero a las curadurías urbanas.

1.2.3 Pevesca Ltda. e Inversiones Vives en Liquidación[7]

31. Pevesca Ltda. presentó contestación de la demanda por intermedio de apoderado judicial, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones y propuso como excepciones las siguientes:

32. Argumentó que no existe vulneración de los derechos colectivos cuya protección solicitan los actores ya que, en primer lugar, el predio identificado con matricula inmobiliaria No. 080-29554 es un bien de propiedad privada, de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, el Decreto 2324 de 1984 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta.

33. Añadió que de conformidad con el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, la Dirección General Marítima no puede desconocer lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, que esa entidad ha incurrido en imprecisiones al definir playa y jurisdicción y, pretende expropiar el predio de la sociedad sin seguir el procedimiento previsto en la ley para tal efecto.

34. Declaró que la Resolución No. 153 de 2008 expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Santa Marta es un acto administrativo en firme, cuya validez no ha sido cuestionada en sede administrativa o judicial.

35. Propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a las sociedades Pevesca Ltda. e Inversiones Vives Ltda. en liquidación.

1.2.4 Ministerio del Medio Ambiente[8]

[6] Ver págs. 133-134 del PDF 01 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.
[7] Ver págs. 188-215 del PDF 01 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.
[8] Ver págs. 312-323 del PDF 01 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

36. Actuando a través de apoderado judicial, la entidad contestó la demanda. Respecto a los hechos planteados en la demanda señaló que se atiene a lo que resulte probado en el proceso y se opuso a cada uno de ellos en lo relacionado con la entidad, pues conforme a las competencias que se le han atribuido en la ley, teniendo en cuenta los hechos narrados en la demanda, el ministerio no debe ser tenido como parte accionada, pues si la problemática se deriva de la expedición de una licencia urbanística en donde no ha intervenido, ni ha emitido permisos ambientales respecto al tema, es claro que no tiene responsabilidad alguna que pueda derivar de actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución de la licencia de construcción en las playas de Santa Marta.

37. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que, según su parecer, el ministerio no es sujeto o parte legitimada dentro de la presente acción, para ser llamado a responder por la supuesta violación de los derechos colectivos invocados por el actor popular.

38. Argumentó que de conformidad a lo dispuesto en la Ley 810 de 2003, que modificó la Ley 388 de 1997, la vigilancia y control de los curadores urbanos puede ser realizada directamente por el Alcalde municipal o distrital, o por su delegado. Así las cosas, el seguimiento sobre la aplicación de las normas urbanísticas por parte de los curadores le corresponde a la respectiva alcaldía y no al Ministerio del Medio Ambiente, cuya competencia se circunscribe a la formulación de la política nacional en relación con el desarrollo territorial y expedir las regulaciones en esa materia, de acuerdo con lo señalado en el numeral 10 del artículo 16 del Decreto 216 de 2003.

1.2.5 Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima – Capitanía de Puerto de Santa Marta - DIMAR[9]

39. La entidad propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no se radica en cabeza de esa entidad la facultad legal para regular y ejecutar las acciones necesarias para recuperar materialmente las áreas de playas marítimas ocupadas ilegalmente.

40. Narró que la entidad mediante Oficio No. 14201001601 MD-DIMAR-CP04-LITORALES-021 del 17 de junio de 2010, dirigido a la Alcaldía Distrital de Santa Marta informó que de acuerdo con inspección de playas del día 13 de junio de 2010, se había observado que al lado del antiguo restaurante Terreza Marina en el sector de "Playa Los Cocos", se encontraban adelantando la construcción de un cerramiento.

[9] Ver págs. 190-199 del PDF 02 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

41. Manifestó que la entidad solicitó al Alcalde Distrital que ordenara el retiro de los materiales de construcción a fin de evitar el mal uso que se hace de aquellos y, que en esa oportunidad también se informó que con anterioridad en el mes de octubre de 2007 se había observado el inicio de la construcción de cerramiento en el mismo lugar, el cual fue oportunamente informado a la Alcaldía Distrital de Santa Marta que a través de Resolución N 047 del 19 de febrero de 2008 ordenó la suspensión de dicha obra.

42. Declaró que se configura la excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no se radica en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima, la facultad legal para regular y ejecutar las acciones necesarias para recuperar materialmente las áreas de playas marítimas ocupadas ilegalmente.

43. Propuso como excepción la inexistencia de la vulneración alegada, en primer lugar, porque dentro del marco de sus competencias la entidad realizó todas las acciones tendientes a salvaguardar la destinación al uso común de dichas playas.

44. Argumentó que informó a la Alcaldía mediante oficio No. 14201001601 MD-DIMAR-CP04-Litorales-021 del 17 de junio de 2010 que en inspección de verificación del área de playa marítima en la Bahía de Santa Marta el 13 de junio de 2010 se observó que nuevamente se encuentran adelantando obras de construcción de un cerramiento al oeste del Restaurante "Terraza Marina"

45. Señaló que, no existe en la actualidad ningún tipo de intervención adicional o construcción de carácter permanente, por lo que considera que no se configura vulneración alguna al goce del bien de uso público de la Nación.

1.2.6 Corporación Autónoma Regional del Magdalena - Corpamag[10]

46. Obrando por intermedio de apoderado judicial la entidad presentó escrito de contestación a la demanda oponiéndose a cada una de las pretensiones en lo que respecta a la entidad que representa, toda vez que, en el marco de las funciones atribuidas a la entidad dentro de su jurisdicción, la construcción u ocupación de bienes de uso público no son de su competencia.

47. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con base a que la entidad es un ente corporativo de carácter público del orden nacional cuya competencia como autoridad ambiental gira en torno a los 29 municipios que conforman el Departamento del Magdalena, así como en el área rural del Distrito de Santa Marta, por lo tanto, no es parte dentro de la presente acción popular ya que, dentro de sus competencias no se encuentran funciones relacionadas con la expedición de licencias urbanísticas o de construcción.

[10] Ver págs. 291-295 del PDF 02 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

48. Solicito la desvinculación de la entidad y en su lugar se vincule al Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente – DADMA-, ya que el objeto de la presente acción se centra en el sector urbano del Distrito de Santa Marta y por ende el DADMA sería la autoridad ambiental competente para intervenir en el asunto.

1.2.7 Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental – DADSA (Antiguo DADMA)[11]

49. La entidad contestó la demanda por intermedio de apoderado judicial manifestando en primer lugar, que en el presente asunto se presenta la carencia actual del objeto por hecho superado, toda vez que, si bien la acción incoada por el actor fue presentada por una invasión del espacio público y la contaminación que a su juicio se producía por los residuos de un cerramiento en la playa los cocos, al momento en que se realizó visita por parte de funcionarios de esa autoridad ambiental, no se encontró ningún tipo de cercamiento en el lugar que obstruyera el paso de los ciudadanos, advirtiéndose que en la zona solo está la construcción del Edificio Bahía Loft Santa Marta.

50. Declaró que, desde la presentación de la demanda hasta la fecha de presentación de su contestación, han transcurrido más de 7 años, tiempo que es suficiente para entender que los hechos que fundamentaron las pretensiones del presenta proceso ya no existen y por ende es necesario la terminación de este.

51. Argumentó que, el actor no demostró las afectaciones o perjuicios colectivos que alega, pues en el presente caso no existe daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos alegados por el actor, de ahí que, no exista razón legal alguna para emitir una orden dentro de la presente acción constitucional, ya que la misma se tornaría innecesaria.

52. Adicional a lo anterior la entidad aseveró que no es la autoridad encargada de otorgar licencias de construcción en las obras que se están desarrollando en el sector de la playa "Los Cocos" pues su función se limita a evaluar las medidas de manejo ambiental.

53. Explicó que las medidas de manejo ambiental son aquellas que se implementan con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad; de ahí, que con las mismas se evite la aparición de un fenómeno ambiental negativo; se disminuye la magnitud o importancia de los impactos ambientales adversos; se anulan, corrigen, y atenúan los impactos recuperables y, se contrarresta la

[11] Ver págs. 336-343 del PDF 02 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

alteración al medio ambiente con realizar acciones con efectos positivos que compensan los negativos imposibles de corregir.

54. Narró que en virtud de ser la máxima autoridad ambiental en el área urbana del Distrito de Santa Marta, expidió la Resolución N° 775 del 19 de agosto de 2014 *"Por medio de la cual se establece la obligatoriedad de la presentación de las medidas de manejo ambiental para el desarrollo de la actividad constructiva de la ciudad de Santa Marta y se toman otras consideraciones"*

55. Explicó que en el mencionado acto administrativo se indicó que, debido al conjunto de actividades que son necesarias para realizar por parte de las empresas encargadas del desarrollo de proyectos constructivos en la ciudad de Santa Marta y que estas tienen el potencial de generar impactos negativos en el medio ambiente, es necesario que esas entidades implementen un conjunto de medidas de manejo ambiental, orientadas a controlar la generación de éstos y consignarlas en un documento que oriente y evalúe la pertinencia de la adopción de éstas para el control y mitigación de los potenciales impactos que se pueden presentar.

56. Manifestó que la Dirección General Marítima y Portuaria es la autoridad que tiene el deber de autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas, la construcción y el uso de islas y estructuras artificiales y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

1.2.8 Ministerio Público

57. No emitió concepto

1.3. De la sentencia de primera instancia[12]

58. El Juez Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia de fecha 22 de septiembre de 2019, resolvió declarar la carencia actual del objeto por hecho superado ante la amenaza a los derechos colectivos incoados por el señor Gerardo Lemus Orozco con base en los siguientes argumentos que se transcriben de manera literal para una mejor comprensión:

> "(…) *El actor popular considera que el cerramiento que pretende realizar la sociedad PEVESCA LTDA., sobre un bien de su propiedad –predio identificado con la Matrícula Inmobiliaria No.080-29554, ubicado en la Calle 27 No.1-05- conforme a la Licencia de Construcción No.039 otorgada por Resolución No. 153 de 22 de agosto de 2008 expedida por la Curaduría Urbana No.2 de esta ciudad, se realiza en zona de playa ocupando un bien de uso público, estando por tanto en jurisdicción de la DIMAR, y según el actor*

[12] Ver PDF 03 del cuaderno de primera instancia de OneDrive

popular es dicha entidad quien debe conceder las concesiones o permisos para realizar obras.

Configuración Del Fenómeno De Carencia Actual De Objeto.

El fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto se ha fundamentado, por vía jurisprudencial, en la existencia de un daño consumado o de un hecho superado. En el marco de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que estas figuras se presentan, en el primero de los casos, cuando se afectan de manera definitiva los derechos del tutelante antes de que el juez haya adoptado una decisión sobre la solicitud de amparo (por ejemplo, la muerte del accionante)3 . En cuanto al hecho superado, el alto Tribunal ha afirmado que el mismo tiene lugar cuando, "por la acción u omisión [...] del obligado, se supera la afectación de tal manera que 'carece' de objeto el pronunciamiento del juez. [...] En efecto, si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual 'la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío.

El Consejo de Estado ha adoptado idéntico criterio para evaluar si el fenómeno de carencia actual de objeto se ha presentado o no en el curso de una Acción Popular. En reciente sentencia6 , reiteró la jurisprudencia sentada desde 20037 , según la cual este tiene lugar ante las siguientes dos circunstancias: i) la primera de ellas, cuandoquiera que se ha superado la afectación de los derechos e intereses colectivos y no es procedente ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, por no ser ya necesario; o ii) cuando acaece un daño consumado y no es posible acudir a la restitución. Cuando tales supuestos se presentan, la orden judicial sería inocua, por lo cual deben denegarse las pretensiones.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, mientras permanezcan vigentes los hechos que han dado lugar a la interposición de la demanda, no se configura el fenómeno de la carencia de objeto8 . Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando la autoridad administrativa ha adelantado alguna actuación tendente a la superación de la situación que ocasiona la vulneración o amenaza de los derechos, sin que ello implique que cesó la conducta o los hechos que dieron lugar al reclamo de amparo de dichos derechos.

El Consejo de Estado ha mantenido de forma reiterada que, a pesar de que en el curso del proceso se alegue la superación de la situación que dio lugar a la instauración de la demanda, es necesario que se pruebe tal circunstancia y que el juez "verifique el cese de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos aducidos por el actor popular" y, en caso de encontrar que la amenaza o la vulneración subsiste, no es posible declarar el hecho superado.

A juicio de este Despacho, como se encontró probado en el presente asunto la construcción en el predio de Inversiones Vives en

Liquidación, por la cual los actores populares manifiestan se vulneran los derechos colectivos, inició una vez la Curaduría Urbana No.2 concedió la Licencia de Construcción en la modalidad de cerramiento No.39 de 22 de agosto de 2008, la cual en el numeral 1 de las observaciones señala: "1. Esta LICENCIA tendrá una vigencia de 24 meses, prorrogables a 36 meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los 30 días calendario anteriores al vencimiento de la misma Licencia siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra."

De la misma forma, quedó probado en el presente asunto que en diligencia de indagación preliminar dentro de la investigación disciplinaria realizada por la Procuraduría Provincial de Santa Marta, rendida el 17 de mayo de 2011, por la señora SARA URIBE SALAS, Curadora Urbana No.2 de la ciudad de Santa Marta para la época de los hechos, esta manifestó: "Por otro lado, es importante anotar que la licencia que se expidió mediante resolución 153 del 22 de agosto de 2008 perdió vigencia desde el mes de agosto de 2010, puesto que dentro del término de los 24 meses no se ejecutó la obra y adicionalmente en el mes de mayo del año 2009 PEVESCA LTDA solicitó una modificación de la licencia pero la misma se entendió desistida por cuanto no se aportaron los requisitos establecidos, es decir en este momento dicha licencia no se encuentra vigente."

La anterior declaración encuentra sustento legal no solo por lo indicado en el numeral 1 de las observaciones de la licencia de Construcción No.39 de 22 de agosto de 2010, sino en lo contenido en el numeral 6 del mismo documento que reza: "6. La Licencia perderá fuerza ejecutoria cuando se presente algunos de los casos contemplados en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.", norma que disponía:

> *"Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:*
>
> *1. Por suspensión provisional.*
>
> *2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.*
>
> *3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.*
>
> *4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.*
>
> *5. Cuando pierdan su vigencia."*

Es claro que en el presente asunto el acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de Construcción No.39 de 22 de agosto de 2008 perdió su fuerza ejecutoria por cuanto además de ser suspendido, perdió su vigencia, de tal forma que si la obra no fue ejecutada en el término concedido en la licencia, la misma perdió su

vigencia, por lo que hoy en día no surte efectos, por ende no puede realizarse la obra.

Este Despacho Judicial precisa, que si bien la norma en cita fue derogada por la Ley 1437 de 2011, esta mantiene la misma postura legal en su artículo 91, así:

> *"Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:*
>
> *1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*
>
> *2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.*
>
> *3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.*
>
> *4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.*
>
> *5. Cuando pierdan vigencia."*

Ahora, este Despacho Judicial advierte que sobre la competencia de la Dirección General Marítima –DIMAR- en materia de construcciones y ocupaciones temporales de playas y terrenos de bajamar, mediante el pronunciamiento del 2 de noviembre de 2005, Radicación No. 1682, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Magistrado Ponente Doctor Enrique José Arboleda Perdomo, puntualizó le corresponden los siguientes asuntos administrativos:

> *" (…)*
>
> *- Emitir concepto técnico favorable, como requisito previo para las licencias de construcción que corresponde otorgar a las autoridades distritales, municipales o del Departamento de San Andrés y Providencia, cuando las playas y terrenos de bajamar han sido incorporados al perímetro urbano. - Otorgar la autorización, licencia o permiso, para construcción y ocupación temporal de las playas o terrenos de bajamar, cuando éstos se encuentran en la zona rural, con sujeción a las normas que sobre usos del suelo haya definido el municipio o distrito en su Plan de Ordenamiento Territorial.*
>
> *(….)".*

En el curso de la Acción Popular, la Dirección General Marítima –DIMAR manifestó con la contestación de la demanda que "de acuerdo con las inspecciones periódicas que realiza la Capitanía de Puerto en las áreas de bienes de uso público sometidos a su jurisdicción, el día 22 de febrero de 2016 11 , los funcionarios del Área de Litorales de la Capitanía de Puerto de Santa Marta evidenciaron lo siguiente: "Se procede a verificar el frente de playa del edificio Bahia Loft, donde

se evidencia que no hay ocupaciones indebidas sobre el área con características de playa marítima".

Es claro entonces, que el sector de playa denominada "Los Cocos", es el sector donde está ubicado el predio al cual la Curaduría Urbana No.2 de Santa Marta otorgó la licencia de construcción suspendida en el trámite de esta acción popular mediante auto de 13 de julio de 2010, por tanto tiene características de playa marítima, consecuencialmente está sometida a la vigilancia y control de la DIMAR, y dicha entidad debe en cumplimiento de las funciones otorgadas por el Decreto 2324 de 1984, art.5, numeral 21: "Regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción 12 .", así mismo, la Ley de Distritos -1617 de 2013- si bien coloca en cabeza del Alcalde Distrital la atribución para otorgar permisos en relación con la ocupación de playas, indica que esta atribución se ejercerá conforme la normatividad ambiental, y las demás normas vigentes que regulen la materia y teniendo previo concepto técnico favorable emanado por la DIMAR.

Concluye el Despacho de las normas aplicables al sub-lite, que en todo caso se requiere para el uso de la zona de playa y bajamar, permiso y concepto técnico favorable de la DIMAR, y descendiendo al caso en concreto se echan de menos tales documentos.

- DE LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA.

Conforme a lo expuesto, y en relación con la medida cautelar decretada en el presente asunto mediante auto de 13 de julio de 2010, consistente en la suspensión provisional de la Licencia de Construcción No.039 expedida mediante Resolución No.153 de 22 de agosto de 2008, es claro que este acto administrativo ha perdido su fuerza de ejecutoriedad, por haber perdido su vigencia, de tal suerte que no continúa su efectividad una vez se ordene el levantamiento de la medida cautelar. Por consiguiente, no puede llegar a interpretarse que con esta decisión judicial y una vez se levante la medida cautelar decretada, se están prorrogando los efectos del acto administrativo, pues se reitera la -Licencia de Construcción No.039 expedida mediante Resolución No.153 de 22 de agosto de 2008- está vencida.

Lo anterior, lleva a concluir que, en el presente asunto, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues en la actualidad no existe ningún tipo de construcción u obra civil que contravenga el bien de uso público -Playa Los Cocos-.

En sentencia de 29 de agosto de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado reiteró que "la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había solicitado". Y añadió que en caso de materializarse dicha hipótesis, "ya no será necesaria la orden de protección, pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió pero desapareció"

Bajo esta premisa, esta Instancia Judicial declara que la amenaza a los derechos colectivos existió, pues efectivamente la obra civil amparada por la Licencia de Construcción con modalidad de cerramiento No.39 de 22 de agosto de 2008, generó una amenaza

de vulneración a los derechos colectivos al goce a un espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y pescadores del sector, así como de la población turista que frecuenta la Playa Los Cocos, empero, al momento de proferir el fallo ya no es procedente emitir una orden de protección de los derechos invocados, cuando efectivamente la licencia de construcción prementada esta vencida, por lo tanto la obra civil que pretendía realizarse no se ha ejecutado ni puede al día de hoy ejecutarse, toda vez que ese acto administrativo ha perdido ejecutoriedad.

(…)"

59. En la parte resolutiva de la sentencia se consignó:

*"**PRIMERO: DECLARAR** la carencia actual del objeto por hecho superado ante la amenaza a los derechos colectivos incoados por el actor popular GERARDO LEMUS OROZCO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*

***SEGUNDO: LEVANTAR** la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la -Licencia de Construcción No.039 expedida mediante Resolución No.153 de 22 de agosto de 2008-.*

***TERCERO: DECLARAR** según lo normado en el artículo 91 del C.P.A.C.A. que este acto administrativo -Licencia de Construcción No.039 expedida mediante Resolución No.153 de 22 de agosto de 2008- perdió su fuerza ejecutoria por haber perdido su vigencia.*

(…)"

1.4. Argumentos del recurso de apelación[13]

60. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada Pevesca Ltda. interpuso recurso de apelación, con la finalidad de que se revoque la sentencia de primera instancia, sustentado en síntesis en lo siguiente:

61. Argumentó que, el *a quo* incurrió en un error al considerar que el término de la vigencia de la licencia de construcción No. 39 de 2008 venció mientras se encontraba suspendida ya que esta todavía cuenta con la posibilidad de ser prorrogada.

62. Señaló que la mencionada licencia de construcción fue expedida el día 22 de agosto de 2008 con una vigencia de 24 meses, prorrogables a 36 meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria.

63. Trajo a colación que, mediante auto del 13 de julio de 2010, el *a quo* suspendió provisionalmente los efectos de la licencia de construcción No. 039

[13] Ver PDF 06 del cuaderno de primera instancia del expediente de OneDrive.

expedida mediante la Resolución No. 153 del 22 de agosto de 2008 y por tanto su fuerza ejecutoria.

64. En ese orden, declaró que, el *a quo* dio a entender que la vigencia de la licencia expiró por no haber sido ejecutadas las obras aprobadas dentro de los 24 meses, desconociendo que al encontrarse suspendido era obvio que las mismas no podían ejecutarse y por consiguiente realizarse la construcción, colocando en una situación imposible a Pevesca Ltda.

65. Sostuvo que, el término de vigencia de la licencia de construcción terminaba, cuando menos, el día 22 de agosto del 2010, 24 meses desde que entró en vigor, por ende, al haber sido interrumpidos sus efectos el día 13 de julio de 2010, restan más de 30 días de termino de vigencia que se contabilizarán cuando el acto sea ejecutable, es decir, el día siguiente de que sea firme la providencia que levante la suspensión provisional.

66. Argumentó que, bajo ese entendido, la sentencia de primera instancia no solo desconoce lo preceptuado por el C.P.A.C.A en relación con la suspensión de los efectos de los actos administrativos, que para el caso de este proceso es la vigencia, sino además que, al faltar más de 30 días para su vencimiento, Pevesca Ltda., todavía cuenta con la opción de prorrogarla si bien lo tiene.

67. Por otro lado, el recurrente sostiene que el *a quo* concluyó que existió una amenaza al interés público sin una debida motivación y sin referirse a los argumentos expuestos o a las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso judicial, omitiendo de esta forma su deber de proferir una sentencia debidamente motivada.

68. Prosiguió a decir que en el caso concreto la sentencia no realizó una debida motivación para llegar a las conclusiones pues, a pesar de haber citado el trámite procesal y el recuento de las pruebas practicadas, no se evidencia un análisis por medio de los hechos y las pruebas que lleve a concluir la vulneración a los derechos colectivos con base en la sana critica, así las cosas, el juez omitió pronunciarse integralmente sobre el carácter de uso público o privado del predio objeto de la licencia de construcción No. 39 de 2008 y la ubicación del predio objeto de la licencia en zona de playa.

69. Planteó que el *a quo* desconoce el plan de ordenamiento territorial de Santa Marta al considerar que el predio en cuestión es espacio público ya que, la competencia para la identificación y delimitación de las playas y terrenos de bajamar del Distrito de Santa Marta, por tratarse de bienes de uso público por su naturaleza, corresponde al Concejo Municipal a través del Plan de Ordenamiento Territorial previa concertación con la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional.

70. Narró que, dentro del trámite de la Licencia de Construcción No. 39 de 2008, la Secretaría de Planeación de Santa Marta expidió la demarcación No.

22 del 15 de agosto de 2008 en la cual, además de fijar las normas de uso y edificabilidad de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, se indicó que el predio se encontraba por fuera de la jurisdicción de la DIMAR, esto en virtud del parágrafo del artículo 101 de la Ley 388 de 1997.

71. Argumentó que el predio objeto de la acción popular no se encuentra dentro de los 50 metros de jurisdicción de la DIMAR obedece al hecho que el mar y su línea de más alta marea han retrocedido en el sector.

2. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

2.1. Competencia

72. El artículo 16 de la Ley 472 de 1998[14] en concordancia con el artículo 133 del Decreto 01 de 1984 aplicable al momento de la presentación de la presente acción popular, dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

73. Igualmente, el artículo 181 de la citada normatividad establece que son susceptibles del recurso de apelación las sentencias de primera instancia proferidas por los Tribunales y los jueces.

74. Debe aclarar esta Corporación que aunque la Ley 1395 de 2010 en su artículo 57 adicionó el numeral 14 al artículo 132 del Decreto 01 de 1984, en el sentido de señalar que los Tribunales Administrativos conocerían en primera instancia de las acciones populares que se interpusieran en contra de entidades de nivel nacional, tal preceptiva no es aplicable al caso en concreto, como quiera que aquella entró en vigencia el día 12 de julio de 2010 y la demanda de la referencia se presentó el día 22 de junio de 2010 como consta en página 12 del archivo 01 del expediente organizado en OneDrive, lo que

---

[14] ARTÍCULO 16.- Competencia. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia.

Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.

PARÁGRAFO.- Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgados administrativos, de las acciones populares interpuestas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso Administrativos y en segunda instancia el consejo de Estado.

quiere decir que la legislación aplicable era la Ley 472 de 1998 en su artículo 16.

2.2. Trámite en segunda instancia

75. Mediante auto del 22 de agosto de 2022[15], se admitió el recurso de apelación formulado por la parte accionada Pevesca Ltda. e Inversiones Vives Ltda. en liquidación en contra de la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta.

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

76. Cumplidos los trámites propios del proceso, procede la Sala a decidir sobre el fondo de la litis planteada en la demanda objeto de revisión en sede de segunda instancia con el siguiente derrotero: 3.1.) problema jurídico a resolver y tesis del Tribunal, 3.2.) fundamentos legales y jurisprudenciales 3.3) de lo probado en el proceso 3.4.) análisis del caso en concreto, 3.5.) conclusiones, y 3.6.) condena en costas.

3.1. Problemas jurídicos a resolver y tesis del Tribunal

77. Debe la Sala establecer si en el presente caso 1) existió vulneración al derecho colectivo al goce de un ambiente sano por parte de la sociedad Pevesca Ltda. y 2) determinar si se ha configurado el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado tal y como lo declaró el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta.

78. **Tesis del Tribunal.** **Confirmar** la sentencia de primera instancia, por medio de la cual se declaró la carencia actual del objeto por hecho superado ante la amenaza a los derechos colectivos incoados por el actor popular Gerardo Lemus Orozco, por los motivos que se exponen a continuación

3.2. Fundamentos legales y jurisprudenciales que apoyan la tesis del Tribunal

3.2.1 Del goce de un ambiente sano

79. La Constitución Política en su artículo 88 preceptúa que el legislador regulará las acciones populares cuya finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de estirpe similar. Dicha regulación esta prevista en las leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011.

[15] Ver PDF 03 del cuaderno de segunda instancia en OneDrive

80. Tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional[16] como la del H. Consejo de Estado[17], han reiterado que el derecho colectivo es aquel cuyo uso y goce se encuentra a disposición de cualquier persona, sin obedecer, en principio, a algún tipo de condición; es decir que, por oposición al derecho subjetivo, no es posible que el disfrute y, por consiguiente, la titularidad del derecho colectivo recaigan exclusivamente sobre el patrimonio de una sola persona o de un grupo específico de personas.

81. La Ley 472 de 1998 en su artículo 4° al cumplir el mandato del constituyente advirtió que son derechos e intereses colectivos los relacionados entre otros, el derecho al goce de un ambiente sano.

82. Con respecto al derecho al goce de un ambiente sano, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente[18]:

> *"Conforme lo establece el artículo 79 de la Carta Fundamental, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, constituyendo un deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de dichos fines.*
>
> *Este derecho se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual garantiza a su vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el medio social. En este sentido, el ambiente sano es un derecho fundamental para la supervivencia de la especie humana; sin embargo, la vulneración del mismo conlleva en determinados casos, al quebrantamiento de derechos constitucionales fundamentales como la vida o la salud. Por consiguiente, como lo dispuso el constituyente de 1991, el Estado debe garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las medidas encaminadas a obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general, a fin de evitar que se causen daños irreparables a la persona, ya que en tales circunstancias, dicho derecho es susceptible de ser protegido, como se ha expuesto, a través del ejercicio de la acción de tutela.*
>
> *Acerca de la naturaleza y definición del mismo, cabe recordar lo expresado por esta Corporación en sentencia No. C-328 de 1995, MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:*
>
> *"No en vano el constituyente elevó el interés colectivo por el ambiente sano al rango de derecho constitucional. La conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas, es necesaria para garantizar la vida y la salud de todos. Por su naturaleza de derecho colectivo, el ambiente goza de mecanismos constitucionales*

[16] Corte Constitucional, Sentencia C-622 de 2007, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil
[17] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2005. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez, Rad: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP)
[18] Corte Constitucional, Sentencia SU-442 de 1997, Expedientes: T-120.950 y T-124.621 (acumulados), Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.

específicos para su defensa, como son las acciones populares (C.P. art. 88) y los deberes calificados, en cabeza del Estado, para su protección.

....

La protección del ambiente sano y de los recursos naturales es un deber del Estado y de los particulares (C.P. arts. 8, 58 y 95). En virtud de expreso mandato constitucional (C.P. arts. 49, 79, 80 y 334) y de compromisos internacionales contraidos por Colombia (Convención sobre Diversidad Biológica, artículo 14), al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por importante que parezca, puede desconocer.

La Constitución impone al Estado los deberes especiales de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente (1); proteger su diversidad e integridad (2); conservar las áreas de especial importancia ecológica (3); fomentar la educación ambiental (4); planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (5); prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (6); imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente (7); y, cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas (8) (C.P. arts. 79 y 80). Por otra parte, la Carta establece que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado (C.P. art. 78).

En virtud del "Convenio sobre la Diversidad Biológica", suscrito en Río de Janeiro en 1992, y de la Ley 165 de 1994, aprobatoria del mismo, Colombia contrajo el compromiso internacional de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de especial importancia ecológica, entre otras cosas, obligándose a explotar sus recursos naturales de manera que no se perjudique el equilibrio ecológico. La Corte, mediante sentencia C-519 de noviembre 21 de 1994, declaró exequible el convenio y la Ley 165 de 1994".

Ahora bien, del mandato constitucional consagrado en el artículo 79, se colige que es responsabilidad del Estado atender y garantizar la prestación efectiva del servicio público de saneamiento ambiental, conforme a los principios de universalidad y solidaridad. Todas esas obligaciones están dirigidas a la preservación, conservación y protección del medio ambiente, a fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general, según lo determina el artículo 366 de la Carta Fundamental.

Así mismo, la Carta Política consagra los deberes y obligaciones que tienen los asociados frente al ambiente, entre los cuales se encuentra aquel, según el cual, le corresponde a toda persona para proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8 CP.), obrar conforme al principio de solidaridad (artículo 93-2 CP.) y velar por la conservación de un ambiente sano (artículo 95-8 CP.)"

83. De lo anterior se colige que, el goce de un ambiente sano depende del actuar del Estado en la medida que es su responsabilidad atender y garantizar la prestación efectiva del servicio público de saneamiento ambiental para lo cual debe proteger la diversidad e integridad del ambiente.

3.3. Análisis crítico de las pruebas

84. Entre los elementos probatorios aportados al plenario, se destaca lo que a continuación se relaciona:

- Copia de la Licencia de Construcción No. 039 del 22 de agosto de 2008 por medio de la cual se concede una licencia de construcción, a Pevesca Ltda., sobre el predio identificado con el número de Matrícula Inmobiliaria No.080-29554, para cerramiento en bloque con una altura de 0,50 m y con malla electro-soldada en una altura de 1,50 metros, en total el cerramiento tiene una altura de 2,00 metros y una longitud de 94 ML. Vigencia de 24 meses prorrogables a 36 contados a partir de la fecha de su ejecutoria[19].

- Diligencia de inspección ocular practicada por el Inspector de Policía Central de esta ciudad, realizada el 15 de junio de 2010, donde se presentó oposición a la construcción por parte de los moradores y pescadores del sector, y se determinó que el predio sobre el cual se pretende realizar el cerramiento de es de Jurisdicción de la Dimar y es esta última quien debe dar el permiso o concesión frente a la decisiones tomadas por el Inspector de Policía; los querellantes interponen recurso de apelación[20].

- Oficio No. 14201001604 MD-DIMAR-CP04-LITORALES - 021 del 17 de Junio de 2010, librado por la Capitanía de Puerto de Santa Marta, dirigido a Iván Penagos Sala de Ventas del Edificio Bahia Loft, cuyo asunto es: Paralización de obras y restitución de área de playa marítima invadida; informan que realizaron inspección el 13 de junio de 2010, y se pudo evidenciar su denuncia sobre el inicio nuevamente de obras para efectuar un cerramiento en ladrillo sobre una zona de playa marítima – bien de uso público de la nación bajo la jurisdicción de DIMAR, en el sector denominado "Playa Los Cocos", el cual no cuenta con permiso alguno otorgado por la Autoridad Marítima Nacional – Dirección General Marítima DIMAR; así como indica que mediante diligencia realizada por la Inspección Central Permanente Norte ya se había realizado derrumbamiento total de un muro construido en el mismo sitio y la restitución completa de la zona B.U.P. de la Nación[21].

- Resolución No. 047 del 19 de Febrero de 2008, proferida por el Alcalde del Distrito de Santa Marta, por medio de la cual se ordena *la restitución de un bien de uso público indebidamente ocupado por personas indeterminadas*, el cual en su numeral segundo ordena a todas las personas indeterminadas que se crean con derecho alguno sobre la construcción de un cerramiento en

[19] Ver pág. 13 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive.
[20] Ver págs. 17-19 y 73-75 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[21] Ver págs. 21-22 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

bloques de cemento (Pintado de color azul) edificada sobre zona de playa marítima Bien de uso público de la nación, que encierra un área total aproximada de ciento noventa (190 m2), ubicada al lado sur del antiguo restaurante terraza marina del sector de playa de los cocos sobre la carrera 1ª con calle 26 esquina al lado derecho mirando hacia el mar de esta ciudad, ocupación esta que constituye una invasión de un bien de uso público de conformidad con el informe de la Capitania de Puertos contenida en el oficio radicado bajo el No.1420080000038 – CP4-ALITMA – 615. Las obras civiles deben ser objeto de demolición o derrumbamiento voluntario del señor querellado[22].

- Foto aérea del Sector de la Playa "Los Cocos"[23].

- Denuncias de cerramiento de la Playa Los Cocos presentada ante la Secretaría de Planeación Distrital, DIMAR, Secretario de Gobierno Distrital, de calenda 17 de junio de 2010, por los pescadores del sector, en las que solicitan, que mientras se dirime el conflicto presentado sobre quien debería expedir el permiso la Licencia de Construcción otorgada por la Curaduría Urbana No. 2 y la DIMAR, por ser un predio en su jurisdicción, se declare el statu quo del espacio público del área de la playa invadida, la suspensión inmediata de las obras, el cese a la invasión del espacio público y de la violación de nuestras normas legales y constitucionales[24].

- Certificado de existencia y representación legal de Pevesca Ltda, expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta el 21 de junio de 2010[25].

- Certificado de existencia y representación de Inversiones Vives Ltda, expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta el 21 de junio de 2010[26].

- Designación como representante al señor Gerardo Antenor Lemus Orozco de la Comunidad de Pescadores, para presentar Acción Popular o cualquier otra acción que se requiera ejecutar en defensa del interés general por la violación e invasión del espacio público de La Playa Los Cocos que viene ejerciendo la sociedad Pevesca Ltda[27].

- Oficio número 142010012801 de fecha 7 de julio de 2010 expedida por la DIMAR[28] mediante el cual anexa:

- Fotocopias de conceptos técnicos de la DIMAR N° 001-ALITMA-613 del 4 de enero de 2008 y N°027-ALITMA-613 del 20 de mayo de 2008, en los

[22] Ver págs. 23-25 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[23] Ver pág. 26 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[24] Ver págs. 27-32 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[25] Ver págs. 33.38 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[26] Ver págs. 39-43 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[27] Ver págs. 44-45 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[28] Ver págs. 50-65 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

que se determina que el área de construcción llevado a cabo a través de cerramiento hecho en bloques de cemento se encuentra ubicado sobre bienes de uso público de la Nación bajo la Jurisdicción de la DIMAR y como recomendaciones y conclusiones se solicita su restitución, con registro fotográfico y planos[29].

- Fotocopia del acta o informe de inspección realizada el día 13 de junio de 2010 por parte de funcionarios del Área de litorales de la Capitanía de Puertos en la que reposa inscripción a manuscrito que el inspector de litorales señala que se aprecia reinicio de construcción y cerramiento en ladrillo e intervención de la policía impidiendo se continué con la construcción (con registro fotográfico)[30].

- Copia del Oficio 14200900876 de fecha 5 de mayo de 2009 expedido por la DIMAR, suscrito por el capitán de fragata JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL y dirigido al señor Alcalde Distrital de Santa Marta, en la que le solicita se ordene a quien corresponda se tomen las acciones tendientes a la recuperación de bienes de uso público de la Nación, en el que se le pone de presente que se han iniciado nuevamente las obras para efectuar un cerramiento en bloque sobre una zona de playa marítima - Bien de uso público de la Nación, bajo la jurisdicción de DIMAR, en el sector denominado playa los cocos, bahía de Santa Marta, el cual no cuenta con permiso alguno otorgado por la autoridad marítima nacionalDIMAR. Además informa que han sido invadidos y utilizados por parte de PEVESCA LTDA dentro del proyecto denominado "cerramiento en bloque"[31]

- Copia del oficio 14200900899 expedido por DIMAR de fecha 7 de mayo de 2009 y dirigido al señor Alcalde Distrital de Santa Marta la cual denuncia cerramiento de la playa de los cocos[32].

- Copia del oficio número 14200900898 expedido por la Capitanía de Puerto de Santa Marta —DIMAR de fecha 7 de mayo de 2009, dirigido al Alcalde Distrital de Santa Marta en la que solicita la paralización de la obra y restitución del área de playa marítima invadida[33].

- Copia del Oficio Numero 14200901646 de fecha 10 de agosto de 2009, expedida por la DIMAR dirigido al Alcalde Distrital de Santa Marta de la que solicita el retiro de elementos que invaden área de playa marítima[34].

- Copia del oficio número 14201001601 de fecha 17 de junio de 2010 , expedida por DIMAR dirigido al señor Alcalde Distrital de Santa Marta,

[29] Ver págs. 54-63 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[30] Ver págs. 66-68 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[31] Ver págs. 77-78 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[32] Ver pág. 80 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[33] Ver pág. 81 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[34] Ver págs. 83-84 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

en la cual se le pone de presente a la primera autoridad Distrital que nuevamente se encuentran adelantando obras de construcción de un cerramiento al oeste de Terraza Marina y solicita al señor Alcalde ordene a quien corresponda el retiro de los elementos que invaden el área de la playa marítima , a fin de evitar el mal uso que se hace de la playa del sector de los cocos, frente a Terraza Marina, el cual igualmente se encuentra ocupado[35].

- Copia del oficio número 14201001602 de fecha 17 de junio de 2010 expedida por DIMAR dirigido a Pevesca Ltda en la que solicitan la suspensión de las obras para la construcción del cerramiento iniciado sobre áreas correspondientes a playa marítima, bien de uso público de la Nación bajo la jurisdicción de DIMAR[36].

- Copia del oficio número 14200901009 de fecha 20 de mayo de 2009, expedido por la DIMAR con destino al señor Alvaro Luis Vives Lacouture representante legal Sociedad Pevesca Ltda. en la que se le hacen las observaciones del caso en relación a la construcción del cerramiento del área de la playa marítima y se ordena la suspensión del mismo[37].

- Copia del oficio número 14201001632 de fecha 21 de junio de 2010, expedida por la DIMAR dirigido a los pescadores de la Bahía de Santa Marta en la que se le pone de presente la orden de paralización de las obras y restitución del área de playa marítima[38].

- Copia del oficio numero 14200902136 expedido por la DIMAR de fecha 29 de septiembre de 2009, dirigido al representante legal Sociedad Pevesca Ltda. en la que se da respuesta a la petición de suspensión de medidas preventivas[39].

- Copia del oficio número 14201001692 expedido por la DIMAR de fecha 29 de junio de 2010, dirigido al Alcalde del Distrito de Santa Marta en la que se solicita se retiren elementos de fácil remoción que invaden el área de playa marítima[40]

- Copia del oficio 14201001769 en la cual la DIMAR de fecha 7 de julio de 2010, remite a la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta Concepto Técnico Jurídico de la Zona de playa marítima sector "Los cocos"[41].

[35] Ver págs. 87-88 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[36] Ver págs. 89-90 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[37] Ver págs. 91-93 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[38] Ver págs. 95-96 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[39] Ver págs. 97-99 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[40] Ver págs. 100-104 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[41] Ver págs. 105-113 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

- Copia del acto administrativo de calenda 23 de junio de 2010, expedido por la Secretaria de Gobierno del Distrito de Santa Marta, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por Gustavo Gutiérrez Meza contra la Resolución sin número de 15 de junio de 2010, emanada de la Inspección de Policía Central de Santa Marta en diligencia de Inspección Ocular realizada en la misma fecha[42].

- Oficio No.3084 de 20 de noviembre de 2009, remitido por la Secretaria de Planeación Distrital al Capitán de Puerto, por medio del cual se solicita el acto administrativo por la cual se declara esa área como espacio público y los estudios técnicos que la soporta, de igual manera determine cuáles son los predios afectados en el Litoral Costero de Santa Marta e indique la Cédula Catastral y número de matrícula inmobiliaria y el acto administrativo por medio de la cual se afecta los bienes en jurisdicción de la DIMAR[43].

- Certificación de Capitanía de Puerto del 11 de enero de 2002[44].

- Copia Resolución No.1223 de 03/09/1990 de la DIMAR en la cual autoriza Construcción en terrenos jurisdiccionales de Santa Marta[45].

- Certificado de tradición y libertad de 20 de agosto de 2010, del predio de Matrícula Inmobiliaria No. 080-29554 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, Referencia Catastral No.010400610011000, ubicado en la Calle 27 No.1-05, y en la anotación No.2 se lee que fue adquirido por Compraventa por Inversiones Vives Ltda.[46]

- Copia simple de la Resolución 153 del 22 de agosto de 2008 expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Santa Marta, mediante al cual se otorgó la Licencia de Construcción No. 039 en su modalidad de cerramiento[47].

- Copia simple de la Demarcación No. 022 de 2008, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación de Santa Marta[48].

- Copia simple del Oficio No. 1890 del 3 de septiembre de 2009, expedido por la Secretaría Distrital de Planeación de Santa Marta, por medio del cual se informa al Secretario de Gobierno, que una vez realizada la Demarcación No.022 de 15 de Agosto de 2008 a la sociedad PEVESCA Ltda., se tiene que el área de lote donde se pretende realizar la construcción del proyecto se encuentra por fuera de la jurisdicción de la

[42] Ver págs. 136-143 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[43] Ver págs. 145-148 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[44] Ver pág. 155 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[45] Ver págs. 150-153 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[46] Ver págs. 217-218 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[47] Ver págs. 219-221 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[48] Ver pág. 223 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

Capitanía de Puerto (DIMAR), toda vez que se identifica un área de playa de 50.00 metros aproximadamente, de conformidad al Acuerdo No.005 del 2.000 mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial y el Decreto No.2324 de 1984 referente a retiro de playas establecidos en el parágrafo2 del artículo 2.[49]

- Copia simple del Oficio No. 1046 - DIMAR - CP4 - DL del 28 de marzo de 2000, emitido por la Dirección General Marítima, dirigido al Alcalde Distrital donde se señalan los apartes del POT del Distrito de Santa Marta, en los que se solicitan se realicen los ajustes que se indican[50].

- Copia simple de la Certificación emitida por el Capitán de Corbeta Gustavo Adolfo Camacho el 11 de enero de 2002, donde consta que el permiso de construcción del Edificio San Fernando ubicado en la Urbanización Bella Vista se encuentra en trámite[51].

- Copia simple de Oficio No. 14200702183 - CP4 - ALITMA - 021, suscrito por el Capitán Juan Francisco Herrera, por medio del cual se remite a la señora Rosa Eugenia García de Polo, el Informe Pericial de Jurisdicción DIMAR, rendido por Guillermo Díaz González, el cual conceptuó que el predio ubicado en la Carrea 1ª No.26-50 queda condicionado a un proceso de solicitud de concesión ante la DIMAR, en el momento de realizarse cualquier tipo de proyecto dentro de los linderos de este terreno, atendiendo las consideraciones de tipo técnico que determinan que el total del terreno en sus 636, 25 m^2 calculados en el levantamiento planimétrico, se encuentran en playa marítima[52].

- Copia simple de la escritura Pública No. 70 del 13 de febrero de 1957 y de la No. 680 del 25 de agosto de 1962, las cuales se registran en el Certificado de Libertad y Tradición Matricula Inmobiliaria No.080-295654 del predio sobre el que versa el litigio[53].

- Oficio No.1353 de 25 de mayo de 2012 de la Secretaria de Hacienda: informa que, de acuerdo a la información existente en los archivos de la administración, el predio identificado con la Referencia Catastral No.010400610011000 se encuentran registros solo desde el año 1991, cuyos pagos realizados hasta la fecha fueron efectuados los días 27/06/2008 y 25/06/2010, por valor de $15.261.345 y $4.184.954 respectivamente[54].

- Oficio No.820 de 4 de junio de 2012, emitido por la Curadora Urbana No.2 por medio del cual allegan copia del expediente administrativo

[49] Ver pág. 224 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[50] Ver págs. 229-240 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[51] Ver pág. 255 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[52] Ver págs. 277-296 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[53] Ver págs. 297-311 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[54] Ver págs. 483-486 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

radicado en dicha curaduría bajo el No.47-001-2-08-113, así mismo copia auténtica de la Resolución No.153 de 22 de agosto de 2008, haciendo la salvedad que dicho acto administrativo se encuentra sin vigencia, puesto que las obras aprobadas debían ser ejecutadas dentro de los 24 meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo, existiendo la posibilidad de que fuera prorrogado, no obstante no se realizó trámite de prórroga. De la misma forma allega acta de Versión Libre rendida por dicha funcionaria ante la Procuraduría Provincial de Santa Marta dentro de la investigación disciplinaria Rad. 2010-237662 el 17 de mayo de 2011[55].

- Oficio No.1055 de 15 de junio de 2012, por medio del cual la Alcaldía Distrital de Santa Marta allega en medio magnético el Acuerdo No.005 de 2000, por medio del cual se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Santa Marta junto con la cartografía que hace parte integral de ese Estatuto, así como también en medio físico copia auténtica del Plan de Desarrollo "EL REENCUENTRO" expedido para el período comprendido entre el año 1992-2002[56].

- Carta Catastral Urbana, expedida por Instituto Geográfico Agustín Codazzi[57].

- Inspección Judicial realizada el 6 de febrero de 2013[58].

- Dictamen pericial rendido el 3 de mayo de 2013por el Perito Felix Rovira Ciceres, a fin de determinar aspectos técnicos del predio referenciado[59].

- Documento Formato Inspecciones de Litorales de la DIMAR, Informe No.018 de 22 de febrero de 2016[60].

3.4. Caso Concreto

85. La Sala se pronunciará para resolver el recurso de alzada teniendo en cuenta lo siguiente:

86. En este punto, el Despacho sustanciador considera pertinente acotar que objeto de la litis se circunscribe a determinar si en el presente caso existió o no, una vulneración al derecho colectivo al goce de un ambiente sano alegado por el actor popular y si en la actualidad hay motivos para declarar la carencia actual del objeto por hecho superado, por lo tanto, no se pronunciara sobre la legalidad de la licencia de construcción No. 039 en su modalidad de

[55] Ver págs. 495-563 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[56] Ver págs. 564-618 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[57] Ver págs. 77-80 del PDF 02 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[58] Ver págs. 57-65, 67-71 del PDF 02 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[59] Ver págs. 103-110 del PDF 02 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[60] Ver págs. 185-189 del PDF 02 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

cerramiento otorgada por la Curaduría Urbana No. 2 mediante Resolución No. 153 del 22 de agosto de 2008 a Pevesca Ltda.

3.4.1. De la existencia de una amenaza al derecho colectivo al goce del espacio público.

87. El Decreto 2324 de 1984, Por el cual se organiza la Dirección General Marítima y Portuaria, en su TITULO IX. Concesiones y permisos de construcción - CAPITULO I. Generalidades, establece las definiciones de costa nacional, playa marítima y terrenos de bajamar, de la siguiente manera:

> "*Artículo 166. Bienes de uso público. Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren titulo alguno sobre el suelo ni subsuelo.*
>
> *Artículo 167. Definiciones. Para todos los efectos legales se entenderá por:*
>
> *1. Costa nacional: Una zona de dos (2) kilómetros de ancho paralela a la línea de la más alta marea.*
>
> *2. Playa marítima: Zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las olas de temporal.*
>
> *3. Bajamar: La máxima depresión de las aguas o altura mínima.*
>
> *4. Terrenos de bajamar: Los que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando esta baja.*
>
> *5. Acantilado: El área localizada en la zona de costa adyacente al mar, desprovista de vegetación y con pendientes fluctuantes entre los 45º y 90º con altura variable.*"

88. Teniendo en cuenta la definición de playa marítima transcrita, el recurrente considera que no existió amenaza a los derechos colectivos porque en su momento la construcción objeto de la presente acción popular se encontraba dentro de un inmueble privado ubicado fuera de la jurisdicción de la DIMAR, esto de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Planeación de Santa Marta en la demarcación No. 22 del 15 de agosto de 2008 en la cual, además de fijar las normas de uso y edificabilidad de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta, se indicó que el predio se encontraba por fuera de la jurisdicción de la DIMAR.

89. El H. Consejo de Estado – Sala de consulta y Servicio Civil en concepto del 29 de abril de 2014[61], al resolver una consulta planteada por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial respecto de la delimitación de las playas y los terrenos de bajamar, señaló que *"para tener certeza sobre la localización y extensión de las playas, no bastaba con las definiciones generales de la Ley, por técnicas y completas que sean, sino que dicha certidumbre deriva de que autoridades especializadas, a partir de parámetros legales y valiéndose de instrumentos y métodos científicos idóneos, efectúen la delimitación o alinderamiento de las playas y zonas de bajamar siguiendo las costas palmo a palmo".*

90. En el mismo concepto, se dejó claro que la Ley le había atribuido la competencia de delimitar las playas a varias entidades, entre las que se encuentran el INCODER, la DIMAR, los Municipios y Distritos a través de los POT y la NACIÓN, y al referirse especialmente a los Municipios y Distritos Especiales como Santa Marta indicó que en el evento de haber establecido, identificado y delimitado los "suelos de protección" en sus respectivos planes o esquemas de ordenamiento territorial, el área de las playas y los terrenos de bajamar, tal como están definidos en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, no tendría que coincidir o corresponder exacta y necesariamente con la delimitación de los referidos suelos de protección; y que en algunos casos dichos suelos pueden coincidir con las playas y las zonas de bajamar, pero en otros casos los suelos de protección pueden tener un área más o menos extensa que la de las playas y los terrenos de bajamar, de acuerdo con las valoraciones urbanísticas, económicas, sociales y ambientales que haga cada municipio al momento de elaborar y aprobar su plan de ordenamiento territorial o el documento equivalente.

91. Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta evidente que el Distrito de Santa Marta, a través de su Plan de Ordenamiento Territorial tiene la competencia para delimitar sus zonas de playa marítima, y en ese sentido, determinar las normas urbanísticas a seguir alrededor de dicho tipo de suelos de protección.

92. Así las cosas, con el fin de corroborar si el predio se encuentra o no dentro del área de Mar cuya jurisdicción corresponde a DIMAR el Despacho sustanciador hizo un análisis del material probatorio obrante en el expediente.

93. Una vez analizada la Resolución Nº 153 de 22 de agosto de 2008[62], mediante la cual la Curaduría Urbana Nº 2 otorgó licencia de construcción en la modalidad de cerramiento a la sociedad Sociedad Pevesca Ltda., se observa que en su considerando señaló como medidas y linderos del predio

[61] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 29 de abril de 2014, Rad:11001-03-06-000-2010-00071-00, Consejero Ponente: Augusto Hernández Becerra.
[62] Ver págs. 219-221 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

con matricula inmobiliaria Nº 0802954 e inscripción catastral Nº 010400610011000, los siguientes: NORTE: 12 ML con una propiedad de Rosa Bernal de Eidelman, SUR: 12 ML con calle 27 en medio. ORIENTE: 35 ML con predios de CI BANPALMA S.A. **OCCIDENTE: 35 ML frente al Mar Caribe.**

94. Por otro lado, se observó que, dentro del material probatorio se encuentra la copia simple de la Demarcación No. 022 de 2008[63], expedida por la Secretaría Distrital de Planeación de Santa Marta se observa que el limite occidente del predio se encuentra a **50.00 metros con línea recta playa frente al Mar Caribe**.

95. Así mismo, dentro el plenario obran los conceptos técnicos de la DIMAR N° 001-ALITMA-613 del 4 de enero de 2008 y N° 027-ALTIMA-613 del 20 de mayo de 2008[64] en los que se determina que el área de la construcción llevada a cabo a través de cerramiento hecho en bloques de cemento se encuentra ubicada sobre bienes de uso público de la Nación bajo la Jurisdicción de la DIMAR ya que, una vez realizados 3 Apiques o trincheras se determinó que el centro del terreno objeto del cerramiento se encontraba a una distancia menor de 50 metros de la línea de más alta marea y como recomendaciones y conclusiones se solicita su restitución, con registro fotográfico y planos.

96. Dentro del expediente también obra el dictamen pericial rendido el 3 de mayo de 2013[65] por el Perito Felix Rovira Ciceres, a fin de determinar aspectos técnicos del predio referencia. En cuanto a las medidas y linderos del predio el perito afirmó que estos son los siguientes: NORTE: 12 ML con Rosa Bernal, SUR: 12 ML con calle 27 en medio. ORIENTE: 35 ML con predios de CI BANPALMA S.A. **OCCIDENTE: 35 ML lineales y franja de playa de por medio y aguas del Mar Caribe**.

97. Adicional a esto manifestó que una vez tomadas de las distancias desde alta marea y el predio en litigio se pudo determinar que por el nor-oeste desde la línea de alta marea al predio tiene una longitud de **31.47 metros lineales** y, por el sur-oeste desde la línea de marea alta marea al predio presenta una distancia de **49.50 metros lineales**.

98. En este punto se trae a colación lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto Ley 2324 de 1984 referente a la jurisdicción de la DIMAR:

> *"Artículo 2° Jurisdicción. La Dirección General Marítima y Portuaria ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos*

[63] Ver pág. 223 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[64] Ver págs. 54-63 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive
[65] Ver págs. 103-110 del PDF 02 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas supradyacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción, islas, islotes y cayos y sobre los ríos que a continuación se relacionan, en las áreas indicadas;

(…)

Parágrafo 2. Las costas de la Nación y las riberas del sector de los ríos de su jurisdicción en una extensión de cincuenta (50) metros medidos desde la línea de la más alta marea y más alta creciente hacia adentro, están sometidos a la Dirección General Marítima y Portuaria."

99. En virtud de las pruebas recolectadas durante el trámite del proceso y, de la norma en cita, es dable concluir que el predio donde se empezaron obras de construcción en la modalidad de cerramiento objeto de debate en el presente asunto y que se identifica con matricula inmobiliaria Nº 0802954 e inscripción catastral Nº 010400610011000, en se encuentra a una distancia menor de 50 ML del Mar Caribe en dirección oeste, es decir, dentro de la jurisdicción de la DIMAR.

100. Teniendo en cuenta lo anterior, el área donde se pretende hacer una construcción en la modalidad de cerramiento por parte de Pevesca Ltda. tiene características de playa marítima, en consecuencia, está sometida a la vigilancia por parte de la DIMAR y dicha entidad debe regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción en virtud del artículo 5 numeral 21 del Decreto Ley 2324 de 1984.

101. Así las cosas, si bien en el presente asunto, la sociedad Pevesca Ltda. contaba con la Resolución Nº 153 de 22 de agosto de 2008[66], mediante la cual la Curaduría Urbana Nº 2 otorgó licencia de construcción en la modalidad de cerramiento, también lo es que no contaba con un concepto o permiso favorable por parte de la DIMAR, por lo tanto, tal y como disertó el *a quo,* si existió una amenaza al derecho colectivo al goce de un ambiente sano.

102. Por las razones expuestas, para la Sala no es de recibo el argumento planteado por el recurrente de que el *a quo* declaró que, si existió una amenaza al interés público sin una debida motivación ya que, del análisis del material probatorio se puede concluir que si existió dicha amenaza al derecho colectivo de goce de un ambiente sano por parte de Pevesca Ltda.

[66] Ver págs. 219-221 del PDF 01 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

3.4.2. De la carencia actual del objeto por hecho superado

103. Como se dijo en líneas anteriores, para el Despacho sustanciador en el presente caso se ha configurado la carencia actual del objeto por hecho superado, pero por un motivo distinto al dio el *a quo,* y este es que la amenaza al derecho colectivo al goce de un ambiente sano por invasión del espacio público ha cesado, como se expondrá a continuación.

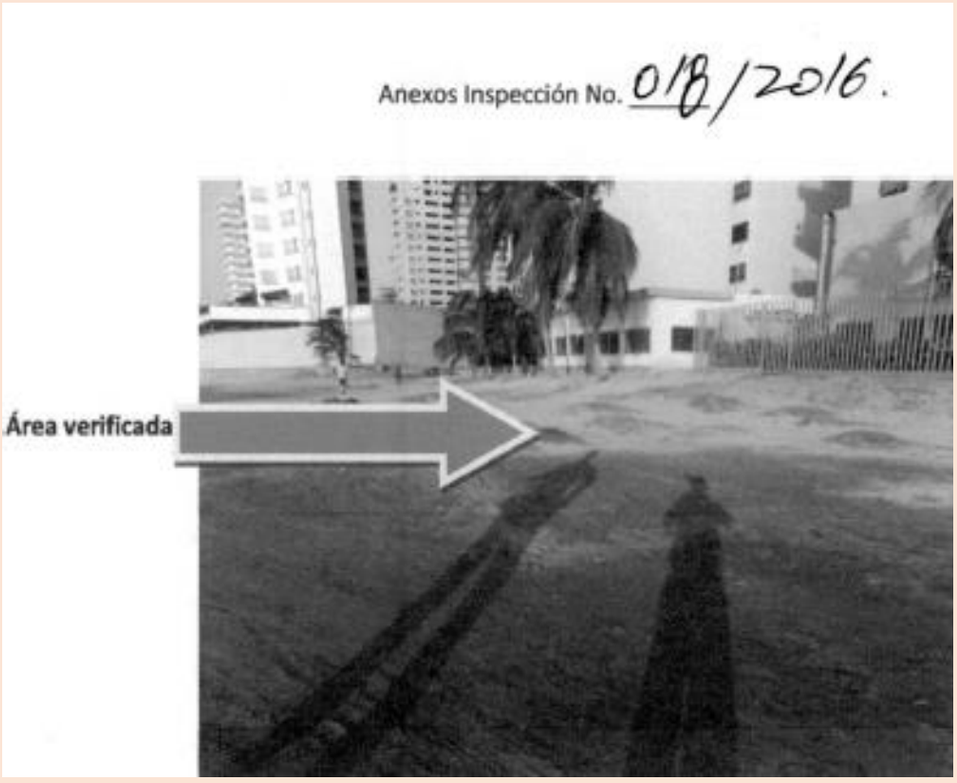
104. Dentro del material probatorio obrante en el expediente también reposa el acta de la Inspección Judicial realizada el 6 de febrero de 2013[67] por el *a quo* en compañía de las partes y el representante del ministerio público donde se consignó que se evidenciaron sedimentos de los cimientos del cerramiento levantado en zona aledaña a la construcción.

[67] Ver págs. 57-65, 67-71 del PDF 02 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

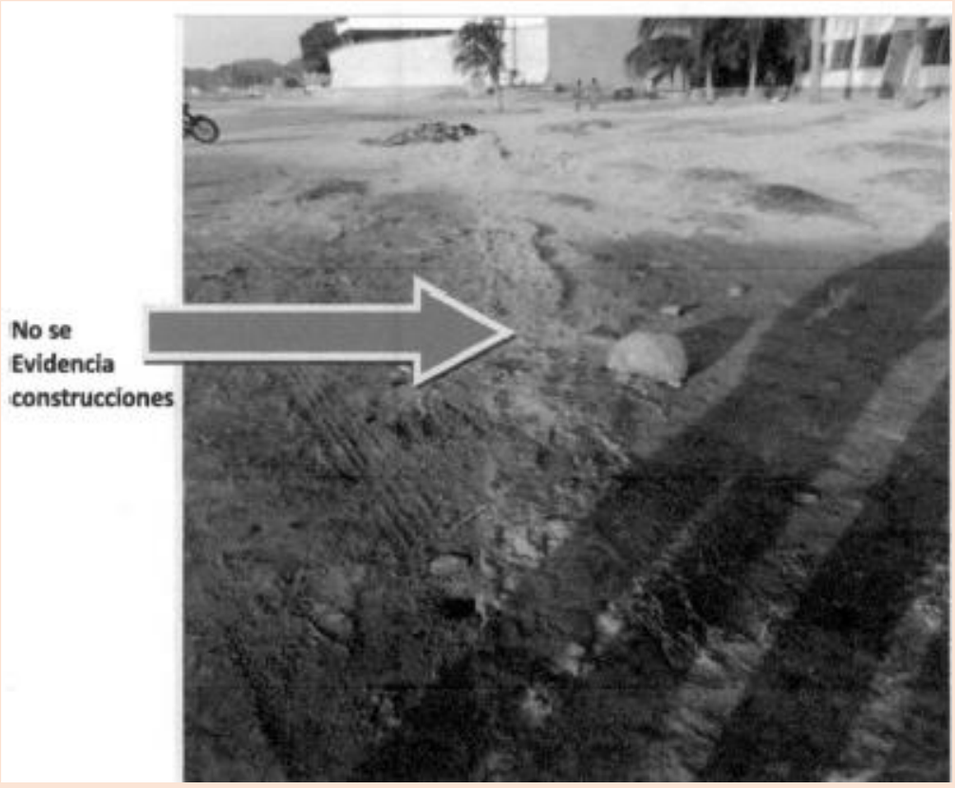
105. En este punto se trae a colación nuevamente el dictamen pericial rendido el 3 de mayo de 2013[68] por el Perito Felix Rovira Ciceres, en el cual plasmo que el inmueble no presentaba ninguna ocupación al momento del peritazgo.

[68] Ver págs. 103-110 del PDF 02 de la carpeta de primera instancia en OneDrive

106. Dentro del plenario también reposa el informe No. 018 de 22 de febrero de 2016[69] de la DIMAR, donde se informó que una vez verificado el terreno ubicado frente al edificio Bahía Loft se evidenció que no hay ocupaciones indebidas sobre el área con características de playa marítima.



[69] Ver págs. 185-189 del PDF 02 de la carpeta de primera instancia en OneDrive



107. De acuerdo con las pruebas anteriormente mencionadas se puede evidenciar que desapareció la amenaza al derecho colectivo al goce de un ambiente sano aducido por el actor popular. Lo anterior por cuanto en la actualidad no existe ningún tipo de obra de construcción dentro del área con características de playa marítima donde la sociedad Pevesca Ltda. pretendió llevar a cabo una obra de construcción en la modalidad de

cerramiento que vulnere el bien de uso público como lo es la playa de "Los Cocos".

108. En razón de lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia del 22 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, por medio de la cual se declaró la carencia actual del objeto por hecho superado ante la amenaza a los derechos colectivos incoados por el actor popular, bajo el entendido de que desapareció la amenaza al derecho colectivo al goce de un ambiente sano aducido por el actor popular debido a que, en la actualidad no existe ningún tipo de obra de construcción dentro del área con características de playa marítima donde la sociedad Pevesca Ltda. pretendió llevar a cabo una obra de construcción en la modalidad de cerramiento que vulnere el bien de uso público como lo es la playa de "Los Cocos".

3.5. Conclusiones

109. Por todas las razones expuestas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta que declaró la carencia actual del objeto por hecho superado.

110. Lo anterior por cuanto en el presente asunto se ha configurado el fenómeno de la carencia actual por hecho superado en razón a que en la actualidad no existe ningún tipo de obra de construcción dentro del área con características de playa marítima donde la sociedad Pevesca Ltda. pretendió llevar a cabo una obra de construcción en la modalidad de cerramiento que vulnere el bien de uso público como lo es la playa de "Los Cocos" por ende, desapareció la amenaza al derecho colectivo al goce de un ambiente sano aducido por el actor popular.

3.6. Condena en costas

111. En virtud de lo establecido en el artículo 171 del C.C.A. procede la Sala a disponer sobre la condena en costas.

112. Las costas están conformadas por dos rubros distintos: las expensas, que corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, y las agencias en derecho, esto es, la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora.

113. En el asunto de la referencia del trámite del expediente no se concluye la causación de las costas y agencias en derecho, razón por la cual no se decretarán.

En mérito de las consideraciones que anteceden, **el Tribunal Administrativo del Magdalena,** administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

Primero. Confirmar la sentencia del 22 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta que declaró la carencia actual del objeto por hecho superado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No hay lugar a condena en costas.

Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 173 del C.C.A, o por medio edicto, en la forma prevista en el artículo 323 del C.P.C.

Cuarto. Una vez ejecutoriada la presente decisión, **devolver** el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA
Magistrada

Firmado electrónicamente
ADONAY FERRARI PADILLA
Magistrado
Con Salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ELSA MIREYA REYES CASTELLANOS
Magistrada

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través del aplicativo SAMAI para Tribunales Administrativos, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el link:
https://retoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

msgma

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

PROCESO : ACCIÓN POPULAR
ACTOR : GERARDO ANTENOR LEMUS OROZCO.
DEMANDADO : NACIÓN – MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y OTROS.
RADICACION : 47-001-3331-005-2010-00684-01

Con el respeto y consideración que les profeso a mis ilustres colegas me permito manifestarles que me separo de lo decidido en el sub iuris, de conformidad con las consideraciones que pasaré a exponer seguidamente.

En relación con el proceso de la referencia, dentro del cual se resolvió confirmar la sentencia del 22 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta que declaró la carencia actual del objeto por hecho superado, me permito efectuar las siguientes consideraciones.

El artículo 16 de la Ley 472 de 1988 ***"****Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones."*, inicialmente reguló la jurisdicción y competencia para conocer las acciones populares, en los siguientes términos:

> ***"ARTÍCULO 16.-*** *Competencia.* ***De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito****. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia.*
>
> *Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.*
>
> *PARÁGRAFO.- Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgados administrativos, de las acciones populares interpuestas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso Administrativos y en segunda instancia el consejo de Estado."*

Posteriormente, se tiene que a través del artículo 57 de la Ley 1395 de 2010 *"Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial".*, se adicionó el numeral 14 al artículo 132 del Decreto 01 de 1984, norma aplicable al presente asunto que establecía en su artículo 132, la competencia en sede de

primera instancia de los Tribunales Administrativos, tal como se cita a continuación:

> *"Artículo 57. El artículo 132 del Código Contencioso Administrativo tendrá un numeral 14, cuyo texto será el siguiente:*
>
> ***14. De las acciones populares*** *y de cumplimiento que se interpongan contra entidades del nivel nacional. (…)"*

(texto en negrillas y subrayas fuera del original)

De la norma transcrita, es dable concluirse que, a partir de la expedición de la Ley 1395 de 2010, las acciones populares en las cuales se dirigiera en contra de una entidad de orden nacional, sería de competencia en primera instancia de los Tribunales Administrativos.

Precisado lo anterior, huelga acotarse que la plurimentada Ley 1395 de 2010, comenzó a regir a partir de la fecha de su promulgación, vale decir, la calenda del 12 de julio de 2010, cuando fue publicada en el diario oficial No. 47768.

Por su parte, sea del caso traer a colación lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en su texto original, esto es, sin la modificación introducida por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, indicaba ad litteram pedem:

> ***"Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir****. Pero* ***los términos que hubieren empezado a correr****, y* ***las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación."***

(Negrillas y subrayas propias)

Después de revisar el expediente del proceso sub júdice, observo que dicho medio de control fue admitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, mediante auto de calenda **13 de julio de 2010**, esto es, cuando ya se encontraba en vigencia la Ley 1395 de 2010 (12 de julio de 2010), la cual se itera, introdujo el numeral 14 al artículo 132 del Decreto 01 de 1984, estableciendo que la competencia en sede de primera instancia, para conocer de las acciones populares dirigidas en contra de una autoridad de orden nacional, sería de los Tribunales Administrativos.

Así pues, en el asunto de la referencia, se impetra el amparo de los derechos colectivos relacionados en los literales a, b, c, d, e, f, g y m del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, presuntamente vulnerados por el DISTRITO DE SANTA MARTA, la CURADURÍA URBANA No. 2, INVERSIONES VIVES LTDA EN LIQUIDACIÓN y el **MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO**, último ente de orden nacional, situación bajo la cual, resulta palmar que la competencia en sede de primera instancia recae en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA.

En este orden de ideas, considera el suscrito que, hay lugar a declarar la nulidad de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta dentro del presente asunto, y se avoque su conocimiento en sede

de primera instancia, pues, la nulidad proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional por expresa disposición del inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento civil (vigente para la época) y que posteriormente fue reproducido por el Código General del Proceso, resulta insaneable.

ADONAY FERRARI PADILLA
Magistrado